

Trata-se a presente Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de TAIS DE CARVALHO FLEMING e WILLIAN GOMES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática do crime disposto artigo 33, caput, c/c artigo 40,

inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Pelo que consta, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 10h25min, na Penitenciária de Pacaembu/SP, situada às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 615, nesta cidade e Comarca de Pacaembu/SP, Tais trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 65,61g (sessenta e cinco gramas e sessenta e um centigramas) de Delta-9 Tetraidrocanabinol (Delta-9-THC), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, Willian teria concorrido, ajustando para que Tais trouxesse consigo o entorpecente.

De acordo com a peça acusatória, os denunciados combinaram de introduzir o entorpecente no interior da referida unidade prisional, local onde se encontrava recluso o denunciado Willian. Consta, ainda, que a denunciada, ao se deslocar a este município para visitar o acusado, seu amásio, trouxe consigo e guardou o invólucro contendo a substância. Narra a acusação que, na oportunidade, durante a revista, a ré foi submetida ao aparelho "scanner", onde os agentes penitenciários constataram a presença de um corpo estranho no interior de seu órgão genital. Citados, os réus ofereceram defesa preliminar às fls. 316 e 318/324.

A denúncia foi recebida no dia 09/03/2022 (fls. 335/336).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (gravação audiovisual) e interrogados os réus (fls. 375/378).

As partes apresentaram alegações finais. Na oportunidade, o Ministério Público postulou pela procedência dos pedidos formulados na denúncia (fls. 375/378). A defesa da ré Tais, alegou que a acusada foi coagida e, em caso de condenação, requer a aplicação da causa de diminuição da pena pela confissão e o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Por sua vez, a defesa do réu requereu a improcedência da ação, ante a falta de provas.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06, pelo laudo pericial de exame definitivo de substância entorpecente de fls. 97/99 e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria dos réus, de igual modo, é evidente.

Não se ignora que o réu Willian negou a prática delitiva.

Disse, em juízo, que não sabia da visita de Tais, pois ela não ia visitá-lo frequentemente e que foi apenas duas vezes. Narrou que não sabe por que a ré fez isso e que não sabia que ia ter visita e foi pego de surpresa. Declarou que foi direto ao castigo e somente após voltar o funcionário falou para ele o motivo. Falou que estavam juntos à época, mas não tinham dinheiro para a visita. Discorreu que Tais apareceu do nada e que não solicitou nada para ela.

Sua negativa, contudo, encontra-se dissociada dos demais elementos constantes nos autos.

Vê-se que a ré Tais confessou os fatos e apontou o réu como coautor do delito. Em juízo, declarou que o réu pedia para ela levar droga. Narrou que se negava a levar a droga, mas nesse dia levou. Às perguntas da defesa, disse que não visitava frequentemente o corréu Willian. Falou que este tinha conhecimento que ela levaria a droga. Declarou, ainda, que não iria receber nada em troca de levar a droga. Falou que além das visitas, recebia ligação de Willian.

A testemunha Rosemeire Hungaro, agente penitenciário, disse, em juízo (gravação audiovisual), que estava prestando serviço na revista feminina e que no corpo da ré, ao passar no aparelho body scanner, foi percebida uma imagem de corpo estranho. Falou que a ré, ao ser indagada, admitiu estar na posse de um invólucro em seu corpo. Narrou que ao levarem a ré a um lugar reservado, esta retirou o invólucro. Às perguntas da defesa, respondeu que tem acesso à ficha do rol de visitas e que constava a ré como amásia de Willian Gomes da Silva. Declarou que a ré visitava o corréu esporadicamente.

Por sua vez, a testemunha Tania Regina Bacaro Mendes, agente penitenciário disse, em juízo (gravação audiovisual), que ao passar pelos procedimentos de praxe antes de adentrar na unidade, pelo scanner, foi verificada uma imagem suspeita no corpo

da ré Tais, que ao ser indagada, confessou que tinha introduzido um invólucro, sendo encaminhada a uma sala isolada onde retirou o objeto. Às perguntas da acusação, respondeu que não perguntam para quem seria a droga e que no dia a ré iria visitar Willian Gomes da Silva.

E, saliento, “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Também, do Col. Superior Tribunal de Justiça: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Como se vê, a acusada foi surpreendida com 65,61 gramas de Delta-9 Tetraidrocanabinol, tentando adentrar unidade prisional em dia de visita e confessou os fatos, declarando que o entorpecente era destinado ao réu Willian, que teria encomendado a droga. Saliente-se que, embora o acusado negue o delito, afirmou que ele e sua amásia estavam juntos à época e que recebia visitas dela. Portanto, não é verossímil que Willian desconhecesse a visita de sua amásia no dia dos fatos, tampouco que a droga não fosse destinada a ele, já que era o destinatário da visita, informação declarada tanto pelas agentes penitenciárias quanto pela ré Tais.

A condenação dos réus por tráfico é, pois, medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena.

#### 1. Tais de Carvalho Fleming

Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não enseja majoração da pena. Não há antecedentes a serem considerados. Igualmente, não existem nos autos informações suficientes sobre a conduta social e personalidade do agente, sendo impossível, portanto, a majoração. Os motivos e circunstâncias do crime, do mesmo modo, não ensejam exasperação, porquanto não exacerbaram a normalidade da figura típica. Assim, fica a pena em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes. Presente a atenuante da confissão, no entanto, a pena já está no mínimo legal (Súmula 231 do STJ), de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última fase, verifico que o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/6, a totalizar 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, assim como 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Incidem ao caso, ademais, a causa de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. É que, para a incidência de referida redutora, necessário o cumprimento de determinados requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedicar o agente a atividades criminosas; (iv) não integrar organização criminosa.

Como se vê, o dispositivo em análise visa a redução da punição ao “traficante de primeira viagem”.

Ensina Guilherme de Souza Nucci:

Causa de diminuição de pena: cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1.º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda (Leis penais e processuais penais comentadas. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2012. p. 263).

No caso, a denunciada é primária e não possui antecedente. Outrossim, das provas constantes nos autos não é possível concluir que ela se dedicava à atividade criminosa como meio de vida ou estava inserida em organização criminosa. Assim, reduzo sua pena em 1/4, o que totaliza 4 (quatro) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Ressalto, por relevante, que o fato de ter sido aplicada a causa de aumento referente ao ingresso de droga em estabelecimento prisional não afasta, por si só, a aplicação da redutora.

Nesse sentido: "4. Não há previsão legal para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando presentes causas de aumento previstas no art. 40 da Lei de Drogas, ainda mais quando cumpridos os requisitos legais para a incidência da minorante (primariedade, bons antecedentes, não exercer atividade criminosa e nem participar de organização criminosa)". (HC 351.362/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016). Contudo, a redução deu-se nesse percentual, inferior ao máximo permitido, em razão das circunstâncias em concreto do delito; vê-se que a acusada fora surpreendida com significativa quantidade de droga não apenas nas imediações da unidade, mas efetivamente tentando adentrar na penitenciária. Tal conduta, além de demonstrar desprezo pelas instituições estatais, contribui para o tráfico e consumo de entorpecentes nos presídios, o que, ainda que indiretamente, fortalece o crime organizado.

Nessa medida, ao fim da dosimetria, resta a pena fixada em 4 (quatro) anos, 4(quatro) meses e 15 (quinze) dias, e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em vista que não há nos autos informações suficientes sobre as condições financeiras da ré.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. Tendo em conta a pena aplicada, entendo inviável a substituição da reprimenda por restritiva de direito, assim como a suspensão condicional do processo.

2. Willian Gomes da Silva

Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não enseja majoração da pena. Igualmente, não existem nos autos informações suficientes sobre a conduta social e personalidade do agente, sendo impossível, portanto, a majoração. Os motivos e circunstâncias do crime, do mesmo modo, não ensejam exasperação, porquanto não exacerbaram a normalidade da figura típica. O acusado ostenta Maus Antecedentes (0001915-75.2014.8.26.0590 - fls. 262) já que "A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos Maus Antecedentes" (STJ - HC: 262254 SP 2012/0273044-0, Relator: Ministra LAURITAVAZ, Data de Julgamento: 04/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe17/02/2014). Assim, exaspero a pena em 1/6, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência (0011358-37.2014.8.26.0562 - fls. 263, 0005200-86.2008.8.26.0590 - fls. 264, 0007578-15.2008.8.26.0590 - fls. 265, 0022622-40.2009.8.26.0590 - fls. 267, 0022639-71.2012.8.26.0590 - fls. 267, 3008212-81.2013.8.26.0590 - fls. 268), nos termos do art. 61, I, do CP, agravo a pena em 1/6, resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias, e 680 dias-multa.

Na terceira fase, atendendo ao disposto no artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06, incide-se a causa de aumento de pena por ter sido o crime cometido nas dependências do estabelecimento prisional. Majoro em 1/6, totalizando 7 anos, 11 meses e 8 dias, e 793 dias-multa.

Não se aplica a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de drogas, posto que reincidente.

Inexistindo outras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva no patamar acima estabelecido.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2.º, do Código Penal, frente à reincidência.

Inviável a substituição da reprimenda ou a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO TAIS DE CARVALHO FLEMING à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inc. III, todos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e CONDENO WILLIAN GOMES DA SILVA à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias, além de e 793 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime disposto no artigo 33, caput c/c artigo 40, inc. III, todos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Concedo aos réus o direito de apelar em liberdade, visto que assim permaneceram durante todo o processo, não havendo nada a justificar a atual restrição de tal direito.

Custas na forma da lei (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado os benefícios da gratuidade da justiça.

Quanto ao entorpecente apreendido, conforme o art. 58, §1º, da Lei n.11.343/06 (Lei de Drogas), anote-se que já foi deferida a incineração às fls. 359.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: 1) Oficie-se o TRE-SP, informando sobre esta condenação, para os fins do art. 71, § 2º, do CE e art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se o Instituto de Identificação Estadual e o Instituto Nacional de identificação, informando a condenação o acusado, para fins de estatística judiciária (CPP, art. 809); 3) Expeça-se a guia para execução definitiva da pena; 4) Expeça-se certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

P.R.I.C

Pacaembu, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA